

第65問

以下の事例に基づき、甲及び乙の罪責について、具体的な事実を摘示しつつ論じなさい（特別法違反の点を除く。）。

- 1 在留資格を得て、A県に在住している外国人乙は、同じ国から来ていたBから一般旅券を不正に取得することを頼まれた。乙は、お金に困っていたため、報酬と引き換えにBの頼みを聞くことにした。そこで、乙は、同県に在住している、知り合いの甲に頼んで名義を借りることで、Bの写真を貼った甲名義の一般旅券を不正に得ようと考えた。乙が、甲に上記事情を話したところ、甲は、お金に困っていたことから、「お前が俺に100万円を支払ってくれるのであれば協力してやってもよい」と言った。これに対し、乙は、報酬の他、同額を手数料としてBに要求すればよいと考え、甲の提案した条件を承諾した。後日、甲は、乙に対して旅券発給に必要な戸籍謄本、住民票、健康保険証を渡し、乙も甲に対し、Bから渡された100万円を支払った。
- 2 数日後、乙は、旅券窓口へ行き、一般旅券発給申請書の本籍欄及び現住所欄に必要事項を記入し、所持人自署欄、申請者氏名欄及び裏面の申請者署名欄にそれぞれ甲の氏名を記入した。その上で、Bの顔写真を添付し、甲名義の一般旅券発給申請書（以下「本件申請書」という。）を作成した。そして、乙は、甲のために甲の代理で申請する者として、本件申請書を他の必要書類とともにA県の旅券発給担当職員Cに提出して、一般旅券の発給を申請した。

なお、一般旅券発給申請書は、申請者本人に対して、一般旅券という公文書を発行すべきか否かを審査するための手続に用いられる文書である。また、所持人自署欄の署名について、①疾病又は身体の故障により署名することが困難な者、②乳児又は幼児等であって、署名する能力のない者、③その他都道府県知事又は領事館が署名することが困難と認める者以外が行うことは、旅券法上禁止されている。これを受けて、本件申請書の所持人自署欄の下部分にも、「（署名は申請者本人が行ってください。）」との注意書きがある。そして、甲は、上記①から③のいずれにも該当しない者であった。

乙の申請を受けたCは、乙に対して、本件申請に関する代理権の授与の事実を証明するものや本人との間柄、代理人自身の身分証明書の確認を求めたところ、乙は、突然、確認を求められたことから、応答に詰まり、甲との間柄について十分な説明をすることができなかった。

そこで、乙は「急にトイレに行きたくなくなってしまったので、少し待っていてください。」とCに伝え、その場を離れた。結局、乙は、一般旅券を取得することはできなかった。

※ 本問は、東京地判平10.8.19を素材とする問題である（以下「素材裁判例」という。）。

第1 乙の罪責

- 1 乙は、甲名義の一般旅券発給申請書を作成しているが、名義人たる甲の承諾を得ている。一般的に、「偽造」とは名義人と作成者との人格的同一性を偽ることを意味することから、承諾を得た場合、人格的同一性を偽ったとはいえず、乙の作成行為は「偽造」とはいえないとも思える（**論点** 名義人の承諾  司H29）。

 273 頁  142 頁

もっとも、判例は、名義人の承諾を得て文書を作成する行為であっても、一定種類の文書に関しては、その性質上、有形偽造に当たるとする（最決昭56.4.8【百選Ⅱ97】、最決昭56.4.16参照）。

素材裁判例も、「本件一般旅券発給申請書は被告人名義であるが、一般旅券発給申請書は、その性質上名義人たる署名者本人の自署を必要とする文書であるから、例え名義人である被告人が右申請書を自己名義で作成することを承諾していたとしても、他人である共犯者が被告人名義で文書を作成しこれを行使すれば、右申請書を偽造してこれを行使したものというべきである。」と述べている。

結論としては、上記場合を有形偽造とする見解が多数を占められるが、素材裁判例と別の理論構成を用いる見解もある。例えば、Bの顔写真が貼付されていることから、本件申請書から認識される人格（＝名義人）は、「そのように（本件申請書通りに）認識される甲」あるいは「公務所に出頭した甲」という架空人であるとも考えることもできる。このように考えれば、有形偽造が成立するのは当然ということになるし、また下記第2において、承諾を与えた者（甲）も当然に（共謀）共同正犯となる。

上記判例の見解によれば、乙には有印私文書偽造罪（159Ⅰ）、同行使罪（161Ⅰ）が成立する。

- 2 本件申請については、詐欺未遂罪（246Ⅰ、250）の成立も考えられる（**論点** 国家的法益と詐欺～証明書類の不正取得）。

 220 頁  100 頁

もっとも、判例（最判昭27.12.25）は、「刑法157条2項には、公務員に対し虚偽の申立を為し免状、鑑札又は旅券に不実の記載を為さしめたる者とあるに過ぎないけれども、免状、鑑札、旅券のような資格証明書は、当該名義人においてこれが下付を受けて所持しなければ効用のないものであるから、同条に規定する犯罪の構成要件は、公務員に対し虚偽の申立を為し免状等に不実の記載をさせるだけで充足すると同時にその性質上不実記載された免状等の下付を受ける事実をも当然に包含するものと解するを正当とする。

しかも、同条項の刑罰が1年以下の懲役又は300円〔注：現行法では20万円〕以下の罰金に過ぎない点をも参酌すると免状、鑑札、旅券の下付を受ける行為のごときものは、刑法246条の詐欺罪に間擬すべきではなく、右刑法157条2項だけを適用すべきものと解するを相当とする。」と述べ、詐欺罪の成立を否定している。

判例の見解によれば、本問でも、旅券不実記載（未遂）罪（157Ⅱ、Ⅲ）のみが成立する。

第2 甲の罪責

名義使用を許諾した甲が私文書偽造罪（同行使罪）の共同正犯となるかが問題となる。

この点について、素材裁判例は、「被告人は文書偽造及び同行使の実行行為自体は行っていないものの、……殊に、本件犯行の実現のためには被告人の関与が不可欠であったこと、65万円という多額の報酬を受領していることなどに照らせば、被告人は自己の犯罪として右犯行に関与したものであるべきであって、共謀共同正犯としての責任を負うものである。（被告人が右偽造文書の名義人であり、単独では正犯にはなり得ないことは右結論には影響しない。）。」として共同正犯の成立を肯定している。

この結論も概ね学説により支持されているが、その理論構成は様々である。

名義人でないことを身分として（消極的身分犯）、65条1項を適用して共同正犯の成立を認める見解もあるが、そもそも、判例・通説は、消極的身分犯なる概念を認めていない（大判大3.9.21参照）。単独では、作成名義人は私文書偽造罪の主体になり得ないとしても、作成名義人以外の者と通じて、私文書偽造罪の実行行為をすることで文書に対する社会的信用を侵害することができるから、65条1項を介することなく、共同正犯の成立を肯定してよいように思われる。

この点について、上記のように、名義人を「そのように（本件申請書通りに）認識される甲」あるいは「公務所に出頭した甲」と捉えれば、そもそも、甲自身は作成名義人ではないから、共同正犯となり得るのは当然である。

上記の点が共同正犯成立の障害とならないのであれば、（共謀共同正犯論を肯定することを前提として、）甲は、乙に成立する上記各罪について共同正犯となる（**論点** 共同正犯の成立要件（共謀共同正犯論）**論** 司 H20,H24,H27,H28,H29,R3,予H24,H27,IBH7-1,H14-1,H15-1,H18-1）。

 139 頁  55 頁

第1 乙の罪責

- 1 乙が本件申請書を他人名義である「甲」名義にて作成し、これをCに対して提出していた行為について、有印私文書偽造罪（159 I）及び同行使罪（161 I）が成立しないか

↓

問題ない要件の検討

↓

名義人の承諾がある場合の「偽造」の成否

↓

文書の性質上、その名義人自身による作成だけが予定されている文書については、本人による名義使用の許諾は意味をなさず、人格の同一性を偽るものとして、「偽造」となる

↓

あてはめ

↓

有印私文書偽造罪及び同行使罪成立

↓

- 2 詐欺未遂罪の成否

↓

国家的法益に対する詐欺罪の成否

↓

詐欺（未遂）罪不成立

↓

旅券不実記載未遂罪（157 II、III）成立

第2 甲の罪責

- 1 名義人である甲が共同正犯（60）となるか

↓

- 2 可罰説

↓

意思連絡と正犯意思があれば、共同正犯となる

↓

- 3 あてはめ

第3 罪数

甲及び乙には、有印私文書偽造罪、同行使罪及び旅券不実記載未遂罪の共同正犯が成立し、牽連犯（54 I 後段）となる

第1 乙の罪責

1 乙が本件申請書を他人名義である「甲」名義にて作成し、これをC
 に対して提出していた行為について、有印私文書偽造罪（159条1
 項）及び同行使罪（161条1項）が成立しないか。

(1) 本件の一般旅券発給申請書は、旅券発給申請有資格者という社会生
 活上交渉を有する事実を証明する文書といえ、「事実証明に関する文
 書」（159条1項）に当たる。乙は、これに一般旅券を得るとい
 う「行使の目的」で甲の「署名」「印章」を記載・押印しているが、こ
 の行為が「偽造」といえるか。

(2) 「偽造」とは、文書に対する社会的信頼を保護すべく、人格の同一
 性を偽ることを言うところ、乙は名義人である甲から承諾を得てお
 り、人格の同一性を偽ったとはいえないとも思われる。

確かに、一般に名義人が承諾をしている場合には、その者が当該文
 書を作成させたこととなるから、人格の同一性が偽られることにはな
 らないと解するのが原則である。

しかし、文書の性質上、その名義人自身による作成だけが予定され
 ている文書については、別に考える必要がある。作成者と名義人の同
 一性が厳しく要求される場合だからである。このような場合は、本人
 による名義使用の許諾は意味をなさず、人格の同一性を偽るものとし
 て、「偽造」となるといふべきである。

(3) 本件申請書は、申請者本人に対して、一般旅券という公文書を発行
 すべきか否かを審査するための手続に用いられる文書であって、所持

1

人自書欄の署名について、申請者以外の者が行うことができるのは極
 めて例外的な場合である。

そうだとすれば、本件申請書は作成者と名義人の同一性が厳しく要
 求される文書であって、名義人甲の承諾は意味をなさない。

したがって、人格の同一性を偽るものといえ、「偽造」に当たる。

(4) 以上から、上記行為に有印私文書偽造罪が成立する。

(5) また、乙は、Cに対して、同申請書を真正なものとして提出し、そ
 の内容を認識させているから、偽造文書を「行使」したものとして、
 同行使罪が成立する。

2 次に、乙は、偽造した本件申請書を用い、一般旅券の不正取得を企
 てているものの、その目的を達していない。この行為に、「人を欺い
 て財物を交付させ」ようとしたが、「これを遂げなかった」（43条
 本文）として、詐欺未遂罪（250条、246条1項）が成立しない
 か。

(1) これは国家に向けられた欺罔行為である。個人的法益に対する罪で
 ある本罪が国家に対して成立し得るのか。

詐欺罪の保護法益たる財産権は、当然国家にも観念し得る。そこ
 で、財物交付の具体的目的、財物の内容・性質などの諸事情を考慮し
 て、個別具体的に詐欺罪の成否を決すべきである。

これを一般旅券についてみると、一般旅券は証明手段としての価値
 しかない財物である。これを不正に取得しても、交付者が経済的に重
 要な目的を達成できなくなるとはいえないから、交付の判断の基礎と

2

なる重要な事項を偽ったとはいえず、「欺」く行為を認めたい。また、157条2項が旅券について特に軽く処罰していることとの均衡を図る必要がある。

これらのことに鑑みれば、一般旅券の不正取得は詐欺罪を構成しないというべきである。

(2) したがって、上記行為につき、詐欺未遂罪は成立しない。

(3) もっとも、上記行為につき、「公務員に対し虚偽の申立てをして、……旅券に不実の記載をさせ」ようとしたものとして、旅券不実記載未遂罪(157条2項、3項)が成立する。

第2 甲の罪責

1 上記の乙の罪について、承諾を与えている甲の罪責をいかに考えるべきか。特に、文書偽造罪に関しては、甲は当該文書の名義人であり、少なくとも単独正犯たり得ない。そこで、甲について、上記行為について共同正犯(60条)となり得るか、検討する必要がある。

2 この点について、名義人も行為者を通じて、間接的に文書偽造罪の保護法益である文書に対する社会的信用を害することができるから、単独正犯とはなり得なくとも共同正犯とはなり得るというべきである。

そして、60条が一部実行全部責任を規定する趣旨は、相互利用補充関係による共同犯行の一体性にある。そこで、実行行為に関与していない者も、そのような関係が認められれば共同正犯となり得る。

具体的には、共同性を基礎付ける意思連絡及び正犯性を基礎付ける正犯意思が認められる場合には、共同正犯となると解する。

3

3 本問では、乙は、甲に対して、一般旅券発給を甲名義で取得するためにその名義使用を求め、甲はこれに承諾したので上記各行為(犯罪)について意思の連絡が認められる。

また、甲はその対価として100万円を自ら要求し、その利益の帰属が認められる。加えて甲の名義使用の許諾は、乙が不正に甲名義の一般旅券を取得するために不可欠となる行為であるためその役割は大きい。これらの事情からすれば、甲に上記各行為について正犯意思が認められる。

したがって、甲は、乙に成立する上記各罪について、共同正犯となる。

第3 罪数

乙には、有印私文書偽造罪、同行使罪及び旅券不実記載未遂罪が成立する。これらは、それぞれ手段目的の関係であるから、牽連犯(54条1項後段)となる。

甲は、これらの各罪について乙と共同正犯の関係に立つ。

以上

4